

1521963-19.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... de sua residência, para fins de tráfico, diversas porções de maconha, parte delas individualmente embaladas para facilitar a tradição, e cocaína, além de munições do calibre .20. Ocorre que Policiais Militares, em patrulhamento de rotina pela região, conhecida como "ponto de tráfico", visualizaram o denunciado correndo por uma viela, em atitude suspeita. Perceberam que ele ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521963-19.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521963-19.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261764/2022 - 11º D.P. SANTO AMARO, 27643145 - 11º D.P.

SANTO AMARO, 2261764 - 11º D.P. SANTO AMARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON DA SILVA MESQUITA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

CLEITON DA SILVA MESQUITA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, c.c art. 16 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, porque, no dia 24 de setembro de 2022, por volta de 21h30min, na Rua Primo Moratti, 10, Jardim São Luís, nesta cidade e Comarca de São Paulo:

FATO 1: guardava e mantinha em depósito, para a entrega ao consumo de terceiros, i) 392 invólucros contendo Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, na forma de fragmentos vegetais, com peso total de 652,2g (seiscentos e cinquenta e dois gramas e dois decigramas), ii) um invólucro plástico contendo Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, com peso de 608,3g (seiscentos e oito gramas e três decigramas) e iii) 90 (noventa) embalagens contendo Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha, prensadas na forma de bastonetes, com peso total de 426,4g (quatrocentos e vinte e seis gramas e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme boletim de ocorrência de fls. 38/42, auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, laudo de constatação de fls. 49/53 e laudo de constatação

de retificação anexo.

FATO 2: nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, CLEITON DA SILVA MESQUITA possuía e mantinha sob sua guarda munição de uso restrito, consistente em 06 (seis) cartuchos íntegros, calibre 20, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cf. boletim de ocorrência de fls. 38/42 e auto de exibição e apreensão de fls.06/07.

Segundo a exordial, no dia e local dos fatos, CLEITON mantinha em depósito e guardava, no interior de sua residência, para fins de tráfico, diversas porções de maconha, parte delas individualmente embaladas para facilitar a tradição, e cocaína, além de munições do calibre .20. Ocorre que Policiais Militares, em patrulhamento de rotina pela região, conhecida como "ponto de tráfico", visualizaram o denunciado correndo por uma viela, em atitude suspeita. Perceberam que ele adentrou em uma casa e seguiram em sua direção. Quando se aproximavam do local, perceberam que as luzes foram apagadas e ouviram cinco barulhos semelhantes a disparo de arma de fogo. Sentiram forte odor de maconha e entraram na varanda da casa, que estava com a porta aberta. No local, foram localizadas 90 (noventa) invólucros de maconha, na forma de bastonetes; 01 (uma) porção grande de material verde aparentando ser maconha (K2); 392 (trezentos e noventa e duas) pequenas porções de maconha; além de outras 350 (trezentas e cinquenta) porções de substância aparentando ser maconha e uma porção de cocaína. No mesmo local, encontraram 06 (seis) munições calibre.20, uma balança de precisão e diversas embalagens comumente utilizadas no comércio de drogas. Indagado, CLEITON confessou a prática do delito e afirmou que se envolveu com tráfico para "ficar rico". Interrogado em sede policial, o denunciado confessou que estava guardando as drogas em sua residência, mas não indicou quem seria o proprietário (fls. 12/13). Na denúncia foram arroladas as testemunhas VICTOR CRUZ SILVA e BRUNO ALMEIDA RODRIGUES.

Recebida a denúncia em 05/10/2022 às fls. 82/84.

O réu foi citado (fls. 109).

Laudo pericial de exame químico-toxicológico definitivo das drogas apreendidas juntado às fls. 112/115.

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 81, sendo o réu primário.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a /responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Tráfico de Drogas e Condutas Afins e de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O topo do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

Por sua vez, o artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, assim descreve o delito de Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito: "Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas à posse e ao porte de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo

(vontade livre e consciente) de praticar tal conduta.

É crime de mera conduta, consumando-se no momento da ação, independentemente de qualquer resultado.

Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não é necessária perícia na arma de fogo para configuração de crime de posse/porte do Estatuto do Desarmamento (arts. 12, 14 e 16), pois são delitos de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva.

No entanto, se, ainda assim, a perícia for feita e concluir que a arma não funciona, não há crime, sendo tal prova ônus da Defesa (STJ, 6ª Turma. AgRg no HC n. 626.888/MS, julgado em 02/08/2022, DJe de 08/08/2022).

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2),/ boletim de ocorrência (fls.38/42), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 6/7), termo de interrogatório (fls. 12/13) termo de depoimento de testemunha (fls. 14/15), termo de depoimento do condutor e recibo de entrega de preso (fls. 16/17), requisição de IC - substância (fls. 19/20), relatório final (fls. 43/45), laudo pericial de exame químico- toxicológico (fls. 49/53), laudo pericial - auto de constatação de substância entorpecente (fls. 98/101), termo de audiência de custódia (fls. 54/57).

A autoria também é certa em relação ao delito de tráfico de entorpecente.

Na delegacia, o réu CLEITON DA SILVA MESQUITA disse que não teria advogado, e que sua namorada estaria presente na delegacia. Afirmou que a droga estaria realmente guardada em sua casa, o que faria para receber dinheiro, pois estaria desempregado desde o começo da pandemia, vez que labutaria como garçom. Declarou que não seria vendedor, e que somente a manteria ali somente para guardar; mas que não sabe apontar quem seria o dono. Por fim declarou que, não seria usuário; e que estaria arrependido.

Em juízo, o réu CLEITON DA SILVA MESQUITA disse que os policiais estavam procurando um traficante que mora embaixo da sua casa. O depoente mora em cima e a lavanderia é comum. Eles bateram na porta, abriu, e disseram que estava preso. Sabia que as drogas eram da pessoa de baixo. Esse rapaz é muito perigoso. Estava dormindo quando eles chegara, se fosse verdade dos tiros tinha saído do local. O traficante era conhecido como "Rico". Mora no local há 5 anos. Na delegacia prestou depoimento e falou a mesma coisa, e mandaram assinar uns papeis. Na hora negou conhecer o rapaz da foto porque ele é muito perigoso.

Embora tenham negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foram incapazes de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

A testemunha VICTOR CRUZ SILVA afirmou que foram fazer incursão em uma comunidade conhecida pela venda de drogas e no primeiro momento as equipes de ROCAN adentraram e o depoente ficou na segurança das motocicletas, as equipes foram pelas vielas e viram um indivíduo que estava na porta de casa e quando o réu viu entrou correndo para casa. Eles com a lanterna começaram a iluminar a casa sentiram odor de entorpecente e a casa estava fechada. Na rua onde o depoente ficou ouviu 5 ou 6 disparos de arma de fogo, não sabe se na direção do depoente ou pro alto. As equipes voltaram para prestar apoio, o depoente ficou abrigado e não sabia da onde vinham os tiros. Então perceberam que os tiros eram para despistar da casa onde estavam. Voltaram para a casa e viram que a TV e as luzes foram apagadas. O seu companheiro adentrou um espaço comum entre as casas o réu se entregou gritando "perdi", não ofereceu resistência, franqueou a entrada na casa, disse que tinha droga para comercialização e que não era usuário e que fazia a guarda para receber dinheiro que a "sua meta era ficar rico". Tinha muita droga, munições, balança de precisão, dinheiro e eppendorff. Ele disse que era garçom, estava desempregado, que não tinha dinheiro para sobreviver, uma história triste. O réu morava no local.

A testemunha BRUNO ALMEIDA RODRIGUES afirmou que estavam realizando patrulhamento a pé devido informações de grande quantidade de drogas e armas. Em conversas com outros policiais obtiveram uma foto de onde estaria armas e drogas escondida em uma casa. Viram uma casa parecida com a foto, foi visualizar dentro com uma lanterna

momento em que ouviram disparo de arma de fogo, voltaram para a via para dar apoio ao policial que estava com as motos. Ficou claro que estavam próximos do local então voltaram para a casa, eram dois andares, foi possível ver o réu que disse "perdi, perdi", ele abriu a porta, e contou que por estar na guarda das drogas ele fez contato com um amigo para que fizessem os disparos e ele pudesse se evadir. Se deslocaram por poucos minutos. O réu informou que trabalhava de garçom, ficou desempregado e ofereceram a casa onde ele pudesse guardar as drogas e não pagasse aluguel.

A versão dos policiais, apesar de algumas inconsistências, foi confirmada pelas imagens dos fatos, já que por volta do 03:59 minutos do vídeo 1 juntado ao feito à fl. 132 é possível ouvir o réu dizer que mora no local há um ano, mas que guarda a droga há menos tempo, bem como momentos antes menciona os preços dos entorpecentes aos policiais, indicando assim que ele seria de fato o responsável pelo entorpecente e gerando assim sua responsabilidade.

Quanto à possibilidade de desclassificação para o delito previsto no topo do art. 28 da Lei 11.343/06, lembro que o §2º deste dispositivo diz que para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. No caso, a diversidade e a quantidade de drogas apreendidas, bem como a abordagem em local conhecido como ponto de tráfico indicam que a posse não era para o mero uso, mas tinha finalidade comercial.

Configurado, assim, o delito de tráfico de drogas, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa",

Já em relação ao delito de porte de arma não é possível dizer o mesmo, pois analisando todas as imagens juntadas em momento algum foi encontrado armamento em poder do réu ou na sua residência.

Pelo contrário, o que se escuta é o policial pedindo a ele a todo momento o "canhão", que ele nega, bem como o policial sem cabelos exigindo de um terceiro no celular que trouxesse o armamento ou o acusado seria levado preso:

"Manda vir o dono aí pra trocar uma ideia com nós 06:05h (...) você está falando que não é do mano então de quem é (...) quem deu os tiros (...) se vocês não vierem trocar as ideias é o mano que vai ser preso (...) nós tá aqui na casa, com a viatura, manda trazer (...) trás o canhão que deu os tiros, trás aqui agora, manda trazer" em descompasso com todo o protocolo a ser seguido.

Sendo assim, não há qualquer prova de que o réu de fato portasse alguma arma, sendo a absolvição medida que se impõe.

Por fim, é de se ponderar no presente feito algumas irregularidades cometidas pelos policiais que além de só acionarem as câmeras quando o réu já estava detido, o que contraria as normas da polícia, percebe-se que em diversos momentos eles colocam as mãos na câmera ou a viram para que não seja possível ver as imagens.

Da mesma maneira, não se sabe o motivo do setor responsável da polícia militar ter enviado os vídeos apenas em sua parcialidade, já que a maioria deles mostra longos minutos sem qualquer relevância para o feito, porém no momento de ingresso na residência e detenção do réu o vídeo está cortado.

Ademais, é possível ver no vídeo aos 15:17 que o policial sem cabelo pega a mão do réu para desbloquear seu celular e passa s próximos minutos vistoriando o aparelho, o que só não invalida o feito porque tal prova não foi usada para incriminar o réu.

Ainda, no vídeo 1, com som, o mesmo policial careca está com um celular vermelho - que aparentemente seria o do réu - e está falando com um terceiro: "Manda vir o dono aí pra trocar uma ideia com nós 06:05h (...) você está falando que não é do mano então de quem é (...) quem deu os tiros (...) se vocês não vierem trocar as ideias é o mano que vai ser preso (...) nós tá aqui na casa, com a viatura, manda trazer (...) trás o canhão que deu os tiros, trás aqui agora, manda trazer" em completo descompasso com todo o protocolo a ser seguido.

Diante de tais motivos, abra-se vista ao Ministério Público para que tome as medidas cabíveis quanto a apuração do ocorrido.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que a culpabilidade do réu é ordinária, não podendo ser tomada como negativa. O acusado não ostenta maus antecedentes (fls. 81). Não há elementos quanto à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime, não podendo, assim, haver prejuízo ao acusado. As circunstâncias e consequências do crime são neutras. O comportamento da vítima também não é relevante no caso. Em vista dessas circunstâncias favoráveis, fixo a pena base no seu mínimo legal, qual seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito de tráfico de drogas.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, e as atenuantes deixo de considerar pois incapazes de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, pois, não havendo prova contundente nos autos de que se dedique a atividades criminosas e integre organização criminosa, pode-se presumir que não se dedique de forma permanente e habitual, à atividade criminosa de traficar drogas, reiteradamente, ou que seja integrante de organização criminosa, situação especial que exige prova cabal e não mera conjectura. Ao que se depreendeu dos fatos, o réu guardava o entorpecente em sua casa, mas não há indícios de que de fato se dedicava à organização criminosa ou tinha participação direta nela. Contudo, considerando a quantidade de droga encontrada, que se mostrou elevada aos parâmetros normais das operações policiais, diminuo a reprimenda supra fixada em 1/2, fixando a pena definitiva em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 250 dias multa.

Não há maiores dados a respeito da situação econômica do réu, e, em razão disto, fixo o dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então.

O cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser feito em regime prisional inicial semiaberto, considerando a primariedade e a quantidade de pena aplicada. Pelo mesmo motivo, faculto eventual apelo em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Em razão da pena aplicada, nos termos do art. 44 do CP, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tampouco o sursis penal. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência, CONDENO o acusado CLEITON DA SILVA MESQUITA, qualificado nos autos, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão no regime semiaberto e pagamento de 250 dias multa, no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33 "caput", da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a causa de diminuição do artigo 33, §4º, do citado diploma legal. E ainda, ABSOLVO o réu das imputações do art. 16 da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, por insuficiência de provas nos termos do artigo 386 VI do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Abra-se vista ao Ministério Público para que tome as medidas cabíveis quanto as supostas irregularidades cometidas pelos policiais conforme filmagens.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Determino, nos termos do artigo 32 c.c artigo 58, § 1ª da Lei 11.343/06, a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, uma vez que não há controvérsia sobre a quantidade da substância ou produto, nem acerca da regularidade do laudo toxicológico.

Declaro o perdimento de todos os valores e bens apreendidos em favor da União Federal, ainda que não se tenha comprovado a sua habitualidade na prática do

tráfico, conforme artigo 63 da Lei n. 11.343/06, que regulamenta o parágrafo único do art. 243 da Constituição, e sua interpretação dada pelo pleno do STF. Oficie-se, para tal fim.

Nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06 e Comunicado CG 2225/18, determino a destruição de eventuais amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

P.I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA